

1500239-26.2018.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO DOUGLAS OLIVEIRA DA ROCHA UNGARETTE e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

PAULO DOUGLAS OLIVEIRA DA ROCHA UNGARETTE e VICTOR VIANA TERKEL, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1500239-26.2018.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500239-26.2018.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO DOUGLAS OLIVEIRA DA ROCHA UNGARETTE e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

PAULO DOUGLAS OLIVEIRA DA ROCHA UNGARETTE e VICTOR VIANA TERKEL, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e PAULO FELLIPE DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Consta que, no dia 04 de setembro de 2018, por volta das 11h49, na Avenida

Transversal Sul, City Bussocaba, nesta cidade e comarca, PAULO DOUGLAS OLIVEIRA DA ROCHA UNGARETTE e VICTOR VIANA TERKELI traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 27 (vinte e sete) invólucros plásticos contendo Tetrahidrocannabinol (THC) ("maconha"), com peso líquido total de 55,1g (cinquenta e cinco gramas e um decigramas), e 62 (sessenta e dois) invólucros plásticos, do tipo "eppendorf", contendo cocaína, com peso líquido total de 13,6g (treze gramas e seis decigramas), e e PAULO FELLIPE DE SOUSA guardava / tinha em depósito, para fins de tráfico, 177 (cento e setenta e sete) invólucros plásticos, do tipo "eppendorf", contendo cocaína, com peso líquido total de 62,13g (sessenta e dois gramas e treze centigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, PAULO FELLIPE possuía arma de fogo com numeração suprimida, consistente na pistola calibre 38, marca Taurus, municiada com 04 (quatro) cartuchos íntegros e 01 (um) cartucho deflagrado, bem como uma caixa contendo 14 (catorze) munições íntegras.

Denúncia recebida em 04 de outubro de 2018 (fls. 167).

Réus citados (fls. 241, 299 e 314). Resposta apresentada (fls. 366/371).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final os réus foram interrogados.

Nas razões finais o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 529/542).

A defesa alegou, preliminarmente, a inadmissibilidade da prova em razão da violação de domicílio. No mérito, pleiteou a absolvição dos acusados por insuficiência probatória. De forma subsidiária requereu a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, regime aberto e aplicação de penas restritivas de direito (fls. 550/561).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em relação à preliminar arguida pela defesa, não há que se falar em inadmissibilidades dos elementos informativos probatórios, uma vez que, após o recebimento da denúncia anônima (fls. 54), os policiais realizaram a campana e a abordagem dos acusados na parte externa do prédio, não havendo a alegada invasão de domicílio.

No mérito, a acusação procede parcialmente. O crime de tráfico de entorpecentes praticados pelos réus Paulo Douglas e Victor, bem como o delito de posse ilegal de arma de fogo praticado por Paulo Felipe foram devidamente comprovados.

Em juízo, os policiais narraram que, com o fim de apurarem denúncia anônima, diligenciaram até o local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Próximo ao muro do pó visualizaram três indivíduos, sendo que um quarto garoto andava mais rápido na direção destes, com uma nota de dez reais nas mãos. Os policiais seguiram para a abordagem, ocasião que um dos indivíduos colocou a mão na cintura, sacou uma arma de fogo, efetuou um disparo e fugiu. O policial José Muniz abordou os outros três – Paulo Douglas, Victor e o usuário Maicon. O policial Sergio tentou perseguir o quarto, não conseguiu alcançá-lo, pois este ingressou em uma mata. Durante revista pessoal, encontrou aproximadamente noventa porções de drogas em uma bolsa com Paulo Douglas e cento e oitenta reais em notas

trocadas com Victor. Os réus teriam confessado a mercancia e Maicon disse que pretendia comprar drogas. Relataram que os réus foram conduzidos à Delegacia e enquanto se confeccionava o auto de prisão em flagrante, adveio a denúncia anônima de que o autor do disparo ainda estava escondido na mata. Com o apoio da equipe de busca, se dirigiram até a mata próxima a um condomínio e localizaram Paulo Felliipe. Com ele encontraram um rádio de comunicação. Nas proximidades encontraram um tubo de metal e dentro acharam a arma com numeração suprimida e com uma munição deflagrada, além de munições e mais drogas (170 porções). O corréu Paulo Felliipe e os objetos encontrados foram levados para Delegacia.

Os réus foram interrogados, negaram as acusações e apresentaram versões próprias. Paulo Douglas disse que estava lavando o carrinho de feira quando os policiais chegaram. Victor aduziu ser usuário e foi comprar drogas no muro do pó. E Paulo Felliipe estava passando pelo local e foi acusado.

Todavia, as versões dos acusados restaram isoladas nos autos. A defesa não produziu qualquer prova que corroborasse as alegações defensivas.

Em relação ao crime de tráfico de entorpecentes imputado aos réus Paulo Douglas e Victor, verifica-se que a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/04), auto de exibição e apreensão (fls. 29/30), laudo de constatação (fls.78/81), laudo de constatação de resquícios de substância entorpecente na bolsa apreendida (fls. 126/128), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 129/131), além da prova oral.

A autoria também é inconteste, já que os policiais visualizaram a movimentação típica de venda de drogas e apreenderam, na posse direta dos acusados, as 90 porções de drogas e 180 reais em dinheiro. Os depoimentos dos policiais foram firmes e estão em harmonia com o conjunto probatório. Embora os depoimentos de policiais, porque envolvidos com a ocorrência, não possam ser considerados como prova máxima, não obstante a relevância da função que exercem, são, tais depoimentos, elemento de prova como qualquer outro. É o que ocorre nos autos.

Neste diapasão, é bom que se ressalte: “os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, suas palavras servem a informar o convencimento do julgador” (RT 616/282-7, 433/383, 715/439 e outros).

O mesmo acervo probatório é firme quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo por parte do corréu Paulo Felipe. Muito embora o acusado não tenha sido detido na posse da arma apreendida, o laudo de exame residuográfico de fls. 202/205 resultou positivo para as mãos do réu.

Ademais, o laudo pericial de fls. 464/470 confirmou a potencialidade lesiva da arma de fogo e dos municiamentos apreendidos, bem como a recenticidade de disparo, o que reforça a acusação e afasta a negativa apresentada pelo réu.

Não há a insuficiência probatória alegada.

Todavia, entendo que necessária a desclassificação da conduta. Apesar de o exame pericial ter atestado que o número de série da arma apreendida está suprimido, o artigo 16, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 penaliza com maior rigor quem porta, adquire, transporta ou fornece arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, sendo que referido inciso está correlacionado ao caput do artigo, que faz menção às armas de uso restrito ou proibido.

Como vem decidindo a jurisprudência, “não se pode, em prejuízo do réu, dizer que o legislador, no inciso IV, quis punir com a pena mais grave, quem porta arma de uso permitido com sinal de identificação raspado, que está previsto no art. 14 da Lei de Armas”, em manifesta desatenção ao princípio da legalidade, que não admite analogia in malam partem. “No rigor técnico, imprescindível que o artigo 14 contivesse um parágrafo agravando a pena do delito (a lei anterior que punia mais gravosamente o agente que suprimia a marca, sinal ou numeração) se a arma estivesse com a marca ou sinal de identificação raspado. Não cabe ao juiz suprir eventual imperfeição legislativa e, como o inciso IV do 16 não especifica a espécie de arma, não se pode estender a pena do artigo 16 (arma de fogo de uso restrito ou proibido) ao porte de arma de uso permitido”.

O Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que “somente a arma de uso proibido pode ensejar as diversas condutas previstas o artigo 16 e parágrafo único, com seus incisos. Não se pode, pois, transplantar o parágrafo único, do artigo 16 da Lei 10.826/03, para o artigo 12 do mesmo diploma. O transplante dessa natureza não é permitido em nossa legislação, ainda mais com o intento de agravar a pena do agente”.

Compreensível a cautela na interpretação do parágrafo único do art. 16 da Lei 10.826/03. Armas de fogo de uso permitido são as convencionais, de uso comum, e em termos legais, todas aquelas que não estiverem incluídas no conceito de arma de fogo de uso proibido. Armas de fogo de uso proibido são aquelas que possuem uma finalidade especial, geralmente de grande calibre, alto poder vulnerante ou capacidade de impacto, grande precisão e tecnologia apurada, que utilizam munição diferenciada, de finalidades bélicas ou de segurança pública, costumeiramente de uso exclusivo das forças armadas ou de órgão especiais, requerendo um treinamento específico para sua utilização e sujeitas a um rigoroso controle de fabricação e armazenamento ou nos termos do art. 16, III do Regulamento 105 <http://jus2.vol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5823>, “as armas de fogo curtas, cuja munição comum tenha, na saída do cano, energia superior a trezentas libras-pre ou quatrocentos e sete Joules e suas munições, como por exemplo os calibres 357 Magnum, 9 mm Luger, 38 Super Auto, 40 S EtW, 44 SPL, 44 Magnum, 45 Colt, e 45 Auto”, sendo atribuição exclusiva do Exército decidir sobre armas e munições e outros produtos controlados que devam ser considerados como de uso permitido ou de uso restrito (Decreto 3.665, de 20/11/00, art. 27, inc. III).

Ou seja, o que o legislador penal visou punir com mais rigor foi a maior potencialidade lesiva da conduta em razão da maior potencialidade lesiva do armamento. A arma de uso permitido não se torna mais vulnerante se a numeração estiver suprimida ou raspada, nada impedindo que o legislador agravasse a pena se constatada tal circunstância, mas desde que o fizesse de forma expressa e adequada, sem a necessidade de “transplantes” in malam partem, como ressaltado no acórdão supra e em descompasso com o princípio constitucional da proporcionalidade. O argumento de que a alteração dos dados individualizadores da arma aumenta o perigo de que esta seja usada para a prática de ilícitos penais cuja investigação e descobrimento da autoria ficam prejudicados, além de presuntivo, destoa do bem jurídico protegido pela lei.

Em decorrência, imperiosa a reclassificação da conduta para o artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.

Por fim, inexistem nos autos provas objetivas de que os entorpecentes encontrados no tubo pertenciam ao réu Paulo Felipe. Os policiais relataram que viram o réu realizando o disparo de arma de fogo, mas não narraram que estava comercializando ou na posse de qualquer substância entorpecente. Ele não foi flagrado na posse de drogas, não realizada a colheita de digitais para o exame pericial, o local não foi devidamente preservado e periciado.

Em que pese os elementos indiciários tenham sido suficientes para o início do processo, a versão esposada na denúncia não foi devidamente demonstrada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em suma, sem provas não se prende, não se acusa, não se condena. Meras suspeitas e presunções não são suficientes para o desfecho condenatório.

No mesmo sentido:

“Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo” (TJSP – AC 133.383-3 – Rel. Egydio de Carvalho – JTJ 140/276).

“Sem embargo da grande quantidade da erva apreendida, havendo peculiaridades que tornam plausíveis as afirmações dos réus de que não pretendiam passar adiante a droga, manda a prudência sejam eles responsabilizados como usuários e não como traficantes. A prova do tráfico há de ser complementada pela acusação; não bastando para sua afirmação a única circunstância de ser grande a quantidade da substância apreendida” (TACRIM-SP – AC – Rel. Tomaz Rodrigues – JUTACRIM 58/339 – grifamos).

Recorro, também, às lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, um mal à sociedade, mal maior é a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do homem. O Estado não pode ser tão mesquinho e delinqüente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas geram mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima possível do ideal”.

Passo à fixação das penas:

- Réus Paulo Douglas e Victor - Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Os réus não ostentam antecedentes criminais. Com lastro no art. 59 do Código Penal, para cada um mantenho as penas-base no mínimo legal.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante menoridade do réu Victor, que será considerada quando da fixação do regime prisional.

Nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, considerando a primariedade dos réus, diminuo as reprimendas em 2/3 (dois terços).

A míngua de demais causas gerais ou especiais de aumento e diminuição, torno como pena definitiva 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando as poucas informações sobre as condições econômicas dos acusados, mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Para o cumprimento das penas de prisão determino regime inicial aberto, em face do montante das sanções e da primariedade.

Neste diapasão, entendo que a exigência legislativa de regime fechado e o impedimento à progressão não atendem o princípio constitucional da individualização da pena, balizado justamente pelos méritos dos acusados. O critério é justo, porque

leva em conta circunstâncias pessoais de cada condenado. Além disso, corrobora a teleologia ressocializadora da pena, porque estimula o bom comportamento carcerário, a higidez psicológica e não rompe as relações sócio-afetivas, tão necessárias para a reinserção do cumpridor de pena na sociedade.

Ora, basta breve experiência na Corregedoria Permanente de Presídios e Cadeia para se perceber, na prática, o desencontro da impossibilidade da progressão com todo o sistema de execução penal, tantas vezes criticado, mas espelho de equilíbrio entre direitos e deveres, que prescreve garantias e punições sem o "afã" dos tempos atuais. Preso sem progressão é preso sem estímulo; certamente voltará em piores condições para a sociedade. Preso com progressão é mais vezes avaliado, está sempre sendo testado na sua autodisciplina antes de ser definitivamente devolvido ao convívio social.

Além disso, o mandamento constitucional "a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito" (art.5º, XXXV) foi por completo ignorado, ao se arrancar do Poder Judiciário a análise, o juízo sobre a progressão do condenado em determinados crimes. Retirado o poder-dever de individualização da pena no processo de execução, é manifesta a interferência do Legislativo sobre o Judiciário, anulando a independência e harmonia dos Poderes da República (arts. 2º e 60, §4, inc. III/CF), com total esquecimento do preceito dignidade da pessoa humana, eleito como valor supremo da democracia.

E não se olvide que a proibição da progressão traz 'condições explosivas' para as administrações prisionais. Nas lições de Alberto Silva Franco, 'nada pior num estabelecimento penitenciário, do que um condenado sem nenhuma perspectiva de ser libertado ou, ao menos, receber regime penitenciário mais favorável, antes do término de uma pena privativa de liberdade, de longa duração' (Crimes Hediondos, 3ª ed. RT).

É chegada a hora do Poder Judiciário assumir o seu verdadeiro papel, não de mero intérprete da 'vontade' - às vezes equivocada - do legislador, mas também de construtor do direito.

O excesso positivista - lei sempre como diretriz justa, a ser imperiosamente seguida, não obstante com ela se produzam iniquidades, incorreções, injustiças, representa posicionamento jurídico ultrapassado.

Estamos com Bastos, que reclama a necessidade de nos afastarmos do dogmatismo, sobremaneira na esfera penal e encararmos o direito em sua própria "realidade histórico-sociológica; exige-se, hoje, do aplicador do direito a conscientização de que a construção do direito parte dele e não exclusivamente do legislador, que nem sempre faz uma leitura correta da premissa fática que lhe é apresentada, formulando leis que, não raro, refletem somente os anseios de uma determinada classe dominante - a qual pertence este mesmo legislador - ou que, por imprecisão e ambigüidade, facilmente se adaptam às concepções pessoais do exegeta. E, se conservam alguma clareza, nada impede que se doutrine ou que se decida contra elas. Daí o caráter da lei como projeto e, não como realidade jurídica, pois o direito se concretiza à custa do suporte fático de outras matrizes, mais ou menos interligadas." provisória já cumprido para fins de progressão.

- Réu Paulo Fellipe - Artigo 14 da Lei 10.826/03

O réu não ostenta antecedentes criminais. Com lastro no art. 59 do Código Penal, mantenho a pena-base no mínimo legal.

Ausentes atenuantes e agravantes.

A minguada de demais causas gerais ou especiais de aumento e diminuição, torno como

pena definitiva 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando as poucas informações sobre as condições econômicas do acusado, mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Para o cumprimento da pena de prisão determino regime inicial aberto, em face do montante da sanção e da primariedade.

Considerando as poucas informações sobre as condições econômicas do acusado, mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para:

CONDENAR PAULO DOUGLAS OLIVEIRA DA ROCHA UNGARETTE e VICTOR VIANA TERKEL, qualificados nos autos, cada um às penas privativas de liberdade de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, em regime aberto, e também cada um ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO AO DIA, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput da Lei 11.343/06; CONDENAR PAULO FELLIPE DE SOUSA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO AO DIA, pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03; e ABSOLVER PAULO FELLIPE DE SOUSA, qualificado nos autos, da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Recursos em liberdade.

Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Osasco, 01 de agosto de 2022.